

1099007-07.2021.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Franquia

Magistrado: Andre Salomon Tudisco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... oportunistas prejudiciais ao tráfico. O princípio "pacta sunt servanda" mostra-se necessário ao giro mercantil na medida em que freia o natural oportunismo dos agentes econômicos" (op. cit - grifado).

Após detida análise dos autos, os réus/reconvintes não demonstraram os fatos que motivariam a responsabilização da autora/reconvinda pelo fracasso da empreitada.

Com efeito, não foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Praca Doutor Joao Mendes, S/N, São Paulo - SP - cep 01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1099007-07.2021.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1099007-07.2021.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Franquia

Requerente e Reconvinte:

Vinho & Ponto Franchising Ltda. Epp e outros

Requerido e Reconvindo:

Canto do Vinho Ltda - ME e outros

Juiz de Direito: Dr. Andre Salomon Tudisco

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual c.c. obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por VINHO & PONTO FRANCHISING LTDA. - EPP em face de CANTO DO VINHO LTDA. - ME, CAMILA HIDEEMI TANAKA, EVANDRO SOUZA ALBERTINI. Alega a autora ter firmado com os requeridos contrato de franquia para a exploração de unidade franqueada na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, na Rua Toshinobu Katayama nº 715, sala 06, Bairro Jardim Caramuru, com prazo de vigência de 5 anos, início em 23/10/2017 e término previsto para 23/10/2022, figurando os réus como sócios operadores e fiadores. Argumenta que os réus solicitaram a mudança do ponto, pois pretendiam utilizar o endereço como restaurante, mas a autora verificou que no novo local foi aberto estabelecimento com denominação "CANTO DO VINHO", que remete ao negócio da franqueadora. Disse que o novo ponto comercial simplesmente ignorou a necessidade de manutenção do negócio

franqueado e, o mais grave, o mix de produtos previsto em contrato deixou de ser observado. Alega que, desde o início de 2020, os réus inadimpliram os valores devidos à fornecedora homologada e, sendo concedido prazo para regularização das pendências financeiras, não houve regularização. Por isso, em 24/09/2020 enviaram notificação extrajudicial, informando-os da rescisão contratual, por culpa dos franqueados, e do dever de cumprimento das obrigações pós-contratuais, de acordo com a cláusula 14.2 do contrato. Sustenta que mesmo assim os réus permaneceram inertes, não sanaram os inadimplementos, nem firmaram o distrato. Requer, desse modo, a tutela provisória de urgência antecipada; e, ao final: a) a confirmação da tutela provisória, ratificando o encerramento das operações da loja de vinhos no interior do estabelecimento comercial "Canto do Vinho", sob pena de multa diária; b) declarar rescindidos os contratos de franquia por culpa exclusiva dos requeridos; c) condenar os requeridos ao pagamento de multa contratual pelo dever de não concorrência, no valor de R\$ 100.000,00, nos termos das cláusulas 16.2 e seguintes do contrato de franquia; d) condenar os requeridos ao pagamento da multa prevista na cláusula 14.3 e item 9 do quadro resumo do contrato, no valor de R\$ 16.500,00, correspondente ao valor proporcional da multa em razão da rescisão por justa causa por violação às obrigações da cláusula 14.3; e) condenar os requeridos ao pagamento da multa prevista na cláusula 14.3 e item 9, no valor de R\$ 27.500,00, correspondente ao valor proporcional da multa pela rescisão precoce, de acordo com a cláusula 14.3; f) determinar o cumprimento das obrigações pós-contratuais pelos réus, como a cessação do uso da marca da autora com a devolução de materiais e manuais (cláusulas 14.4 e 14.7), cumprimento da cláusula de não concorrência (cláusula 16.2) e confidencialidade (cláusula 16.1) (fls. 1/41). Com a inicial advieram os documentos de fls. 42/167.

Facultada a manifestação dos réus sobre o pedido de tutela de urgência (fls. 169). Manifestação dos réus (fls. 183/212).

Deferida a tutela de urgência pleiteada (fls. 213/215).

Contestação ofertada pelos réus, sob os seguintes argumentos: 1 - o dever da autora de adquirir os bens estocados pela franqueada na forma da cláusula 14.5; 2 - a improcedência da ação, porque, a partir de 2019 a saúde financeira da franqueada foi afetada tanto pela mudança imposta pelo Estado no regime do ICMS ST, quanto pelas obrigações tributárias dos contribuintes locais; 3 - o fato de a franqueadora não se adequar à nova sistemática de recolhimento do ICMS ST, levou a franqueada a suspender a compra de mercadoria no período de abril a novembro de 2019; 4 - a partir desse momento, a Canto do Vinho passa a ter dificuldades na condução da operação, sem o apoio devido da franqueadora; 5 - não há nenhum planejamento por parte da franqueadora, sendo que a escolha do ponto comercial e a estratégia de venda foi da Canto do Vinho; 5 - o sistema padronizado desenvolvido pela franqueadora não existe, a Vinho & Ponto não é titular da marca perante o INPI, nem cessionária; ainda, quando a franqueada se mudou para a Rua Monte Alegre, 2655, Vila Planalto, a franqueadora anuiu com padrão arquitetônico, pois nunca houve sua insurgência quanto às novas instalações; 6 - a franqueada ostenta a sua marca própria na unidade, não tendo recebido qualquer material ou suporte da franqueadora; além do que, a própria franqueadora bloqueou as vendas para a franqueada; 7 - não existe uma nova marca, sendo que diversos pedidos da franqueada foram cancelados; a dívida com a fornecedora homologada é de apenas R\$ 35.715,54; 8 - ausência de concorrência desleal, porque a autora e os réus têm públicos distintos. Em sede de reconvenção, os requeridos/reconvintes suscitam as infrações legais e contratuais cometidas pela autora/reconvinda, em síntese: I - a franqueadora não é titular da marca no INPI; II - a autora não possui um sistema de franquia; III - ausência de suporte da autora-reconvinda. Invocam a abusividade da cláusula penal unilateral, a nulidade da cláusula de não concorrência. Pugna, dessa forma, pela devolução da taxa de franquia, no montante de R\$ 17.500,00, corrigidos desde o desembolso até o efetivo pagamento; pagamento da multa contratual prevista na cláusula 14.3, R\$ 16.500,00, pela rescisão antecipada do contrato de franquia; declaração da rescisão do contrato de franquia por culpa da franqueadora; reconhecimento da nulidade da cláusula 16.2 do contrato de franquia; pagamento pela autora reconvinda das verbas sucumbenciais (fls. 218/253). Documentos juntados

(fls. 254/476).

Petição da autora para constar o endereço correto da ré Canto do Vinho, Rua Monte Alegre 2655, Vila Planalto, Dourados/MS e para requerer que os produtos estocados sejam entregues à fornecedora Biolivas, pois os produtos não foram pagos (fls. 480/501).

Réplica e contestação à reconvenção (fls. 505/542).

Tréplica (fls. 546/550).

Instadas, as partes, à manifestação acerca da produção de provas (fls. 551). Os réus pedem juntada de novos documentos, oitiva de testemunhas (fls. 554/555). A autora pleiteia oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes (fls. 556/579).

Petição dos réus (fls. 583/587).

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, tendo em vista que as alegações das partes, os documentos acostados aos autos, permitem a prolação da sentença, independentemente da produção de outras provas, que, no caso, se mostram desnecessárias, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Consigne-se a desnecessidade da oitiva de testemunhas, uma vez que inúteis para o deslinde da controvérsia, de rigor, dessa forma, o indeferimento das provas requisitadas, de acordo com o art. 370, parágrafo único, do CPC.

A propósito, observo que a prova oral pretendida pela autora e pelos réus (fls. 554/555 e 556/574) é desnecessária à luz dos inúmeros documentos já apresentados nos autos e, por si só, não é meio apto para comprovação dos fatos alegados, além do que carece de fundamento o pedido genérico pela apresentação de "novos documentos", visto que incumbe à parte ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações (art. 434, caput, do CPC).

Os pedidos da ação principal são parcialmente procedentes.

Por determinação do art. 2º da 8.955/94, "Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício".

Ademais, acerca das obrigações essenciais vinculadas ao contrato de franquia, ensina Carlos D. A. Braga que "considerando os elementos essenciais do conceito de franquia empresarial (...) podemos identificar algumas obrigações características", sendo que "[a]s obrigações do franqueado consistem basicamente no seguinte: (i) realizar o pagamento da contraprestação devida em razão da licença de uso de marca e da prestação de serviços de assessoria técnica empresarial, normalmente dividida em uma taxa inicial (também chamada de taxa de franquia) e em pagamentos mensais calculados com base em um percentual sobre o faturamento do franqueado (royalties); (ii) oferecer aos consumidores apenas produtos ou serviços sob a marca licenciada pelo franqueador, por ele fabricados ou por quem ele indicar; (iii) observar estritamente as instruções de comercialização dos produtos e serviços estabelecidas pelo franqueador" e que "[a]s obrigações do franqueador, por sua vez, são: (i) conceder ao franqueado o direito de uso de sua marca; (ii) prestar os serviços de assessoria técnica de organização empresarial" (in Tratado de Direito Comercial, volume 6: estabelecimento empresarial, propriedade industrial e direito da concorrência. Fábio Ulhoa Coelho (coord.). São Paulo: Saraiva, 2015. pp. 181).

No caso dos autos, é incontroverso que as partes pactuaram contrato de franquia Vinho & Ponto, em 23/10/2017, com término em 23/10/2022, para operação da unidade franqueada na Rua Toshinobu Katayama, 715, sala 6, bairro Jardim Caramuru, Dourados/MS, posteriormente transferida para a Rua Monte Alegre, 2655, Vila Planalto, Dourados/MS (fls. 62/96).

A autora alega que houve a rescisão do contrato em questão, por culpa da parte ré, ante o inadimplemento reiterado das obrigações contratuais, quais sejam:

I) Mudança do ponto comercial, apesar de autorizada, os réus não mantiveram padrão de unidade franqueada Vinho & Ponto;

- II) Inadimplemento com a fornecedora homologada, embora tenha havido diversos acordos, tais débitos não foram pagos integralmente;
- III) Violação dos padrões arquitetônicos e layout, infringência das cláusulas 8.4 e 8.5 do contrato;
- IV) Violação da cláusula 8.6 do contrato de franquia;
- V) Violação ao dever de confidencialidade e não concorrência (cláusulas 16.1 e 16.2)

No caso em apreço, ficou caracterizada a rescisão por culpa dos réus, nos termos alegados pela autora.

A rescisão contratual vem prevista na cláusula 14.2 do contrato de franquia. A autora enviou notificação extrajudicial ao réus, em 24 de setembro de 2020, informando que, diante da gravidade dos inadimplementos contratuais, não havia outra opção que não o término da franquia (fls. 159/167).

Deflui dos presentes autos que os réus praticaram reiterados inadimplementos contratuais, conforme os documentos e fotografias juntados pela requerente (fls. 6/7, 9/12).

O inadimplemento das obrigações assumidas com a fornecedora homologada, no que se refere à aquisição de produtos, restaram comprovadas pelos relatórios financeiros e notas fiscais de fornecimento (fls. 484/501). Além disso, os réus não trouxeram prova documental de quitação dos aludidos débitos. Portanto, ficou comprovado que, em decorrência de tal inadimplemento, o fornecimento de produtos aos réus fora cancelado.

Quanto à venda de produtos não homologados e a ausência de venda e exposição do mix de produtos vinculados à franqueadora, foram devidamente comprovados, em violação à cláusula 8.6 do contrato de franquia.

No tocante ao inadimplemento contratual de observância aos padrões arquitetônicos e layout, consoante previsto nas cláusulas 8.4. e 8.5, as fotografias atestam a ocorrência (fls. 120/158). Os próprios réus confessam a utilização de marca própria em desrespeito às cláusulas de confidencialidade e não-concorrência (16.1 e 16.2), ao afirmar que "ostenta a sua marca própria na unidade, não tendo recebido qualquer material ou suporte da Franqueadora para adaptação do layout e o tal "padrão arquitetônico" (sic) (fls. 236).

Em suma, quando da mudança de endereço da unidade franqueada, resta cristalina a descaracterização do estabelecimento pelos réus, com utilização de outra denominação, como se pode inferir das fotografias e relatórios trazidos aos autos pela autora.

Destarte, amplamente configurada a rescisão do contrato de franquia por culpa exclusiva dos réus, na data de 24 de setembro de 2020, consoante a notificação extrajudicial enviada pela autora.

Ademais, os réus devem as obrigações pós-contratuais de não-concorrência, encerramento e descaracterização da unidade franqueada, bem como condenados ao pagamento de multa contratual, embora não pelo valor integral pleiteado.

As obrigações pós-contratuais estão assim dispostas no contrato de franquia pactuado entre as partes:

"14.3. Se houver rescisão contratual por justa causa, a parte culpada deverá pagar à outra uma multa contratual rescisória não indenizatória no valor correspondente a quantia descrita no item 9 do Quadro Resumo, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste Contrato e sem prejuízo do direito da parte inocente de demandar perdas e danos da parte culpada."

"14.4. Se o Contrato vencer ou for rescindido, qualquer que seja o motivo, a FRANQUEADA:

(i) até a data delimitada pela FRANQUEADORA deverá encerrar a operação da UNIDADE FRANQUEADA e deverá cumprir todas as suas obrigações e continuar a prestar os SERVIÇOS e oferecer os PRODUTOS da maneira regulada por este Contrato, providenciando todas as medidas necessárias para o encerramento pacífico na data avençada, sem qualquer prejuízo aos consumidores finais, ao SISTEMA ou à MARCA; e

(ii) após a data delimitada pela FRANQUEADORA para encerramento da operação:

a) não mais poderá usar a MARCA onde quer que ela se encontre, seja por meio físico e virtual, nem o SISTEMA da FRANQUEADORA, devendo alterar a fachada e o layout do

imóvel onde ficava a UNIDADE FRANQUEADA, devolvendo todos os documentos que lhe foram entregues em decorrência deste instrumento, em especial os MANUAIS, além de todo o material promocional, de comunicação visual, entre outros que lhe tenham sido entregues em comodato, sob pena de pagar a multa diária prevista no item 4.6 supra.

b) deverá saldar todos os débitos que eventualmente possua junto à FRANQUEADORA, pois, com o término do prazo contratual ou com sua rescisão, todos terão seus vencimentos antecipados, bem como os débitos frente aos fornecedores homologados do SISTEMA e quaisquer terceiros envolvidos na operação, caracterizando obrigações pós contratuais, podendo a FRANQUEADORA se valer deste instrumento como título executivo extrajudicial, caso não venha a cumprir com todos os pagamentos.

c) observar o quanto disposto na Cláusula XVI abaixo."

"14.5. Se houver término contratual sem renovação, ou rescisão do Contrato, por qualquer que seja a razão, a FRANQUEADORA terá a opção para adquirir os PRODUTOS estocados pela FRANQUEADA pelo preço da compra, bem como materiais promocionais, móveis, imóvel e instalações (se forem da FRANQUEADA) pelo preço de mercado vigentes na época da resolução contratual, devidamente depreciados. Se a FRANQUEADORA não exercer seu direito de opção, a FRANQUEADA poderá comercializá-los junto a terceiros, exceto aqueles que tiverem a identificação visual que remeta à MARCA e que não puderem ser descaracterizados, que deverão ser inutilizados completamente."

(...)

"14.7. Ocorrendo término, distrato, expiração do prazo, ou rescisão, por qualquer motivo, deste Contrato de Franquia, a FRANQUEADORA não está obrigada a pagar à FRANQUEADA nenhum valor de bens ou direitos intangíveis, aos quais a FRANQUEADA renuncia expressamente, concordando que eventuais direitos sobre fundo de marketing, perspectivas de rentabilidade e outros direitos relacionados à exploração da UNIDADE FRANQUEADA estarão sempre irremediavelmente vinculados à reputação e aos métodos da FRANQUEADORA, sendo deles decorrentes, razão pela qual a FRANQUEADA de tais direitos não pode participar, com o que concorda, renunciando expressamente a qualquer eventual pretensão desta natureza."

(...)

"16.1. Os documentos e informações fornecidos em razão deste instrumento, de uma parte a outra, deverão ser considerados confidenciais, logo nenhum dos contratantes poderá divulgá-los sem o prévio e expresso consenso da outra parte, sob pena de responsabilizar-se pelos danos decorrentes e de pagar a multa no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na vigência e mesmo após a rescisão ou encerramento deste instrumento, cumulável com a multa rescisória do item 14.3.

"16.2 Durante a vigência deste instrumento e mesmo após o seu término e/ou rescisão por qualquer motivo, durante um período de 02 (dois) anos, a FRANQUEADA compromete-se, por si e por seus sócios e familiares, empregados e prepostos, a não participar como sócio ou administrador, direta ou indiretamente, em qualquer estabelecimento comercial ou sociedade que, por semelhança, operação, administração, local ou marca seja concorrente das LOJAS PRÓPRIAS e/ou de qualquer unidade do SISTEMA ou que possa vir a confundir ou causar confusão nos consumidores finais ou no segmento de comercialização de bebidas, especialmente o vinho, nem explorar direta ou indiretamente (mediante locação, comodato ou sublocação) um negócio na localidade que funcionava a UNIDADE FRANQUEADA para fins de concorrência com o SISTEMA no território nacional ou no exterior, tudo sob pena do pagamento de uma multa, cumulável com aquela prevista no item 14.3 supra, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente atualizada pela média dos índices IGP-M, IPC e INPC, ou quaisquer outros índices que venham a substituí-los até o pagamento, bem como arcar com todos os prejuízos que vier a causar a FRANQUEADORA."

Em particular acerca da cláusula de não-concorrência, Fábio Ulhoa Coelho ensina que "Em relação aos limites materiais, observa-se que a cláusula disciplinando a concorrência é inválida, se impede o contratante de explorar qualquer atividade econômica. A restrição deve necessariamente se circunscrever a determinados ramos de comércio, indústria ou serviço. Para as demais atividades, as partes ficam livres de qualquer obrigação (de não fazer). A propósito da restrição material,

deve-se também considerar inválida a cláusula que impeça o contratante pessoa física de exercer a sua profissão. Por exemplo, o sócio que se desliga de sociedades de engenheiros pode, no instrumento de cessão de cotas, ficar impedido de competir com a sociedade, desde que os termos contratados não alcancem todas as atividades de engenharia para as quais o retirante se encontra profissionalmente habilitado ou preparado" (in Curso de Direito Comercial, v. 1, 19ª ed., pp. 316, São Paulo, Saraiva, 2015 - grifado).

Assim, observa-se que a cláusula de não-concorrência foi adequadamente delimitada às atividades exercidas pela parte ré em que esta concorreria com a parte autora, além do que foi limitada ao período de dois anos após a avença e, ainda, no próprio local em que funcionava a unidade franqueada.

E foi demonstrado o descumprimento das referidas obrigações, o que ensejou a concessão da tutela de urgência - aliás, em sua resposta, os réus não indicam que houve encerramento das atividades.

Assim, devem os réus ser condenados ao cumprimento das obrigações pós-contratuais contraídas nos termos das cláusulas 14.3, 14.4, 14.7, 16.1, 16.2 do contrato de franquia.

Por fim, é necessário que a multa prevista na cláusula 14.3 somente será aplicada uma vez, sob pena de bis in idem, e reduzida proporcionalmente ao tempo restante de contrato, a teor do disposto no art. 413 do CC.

Outrossim, também é devida a multa imposta pelo item 16.2 do contrato (fls. 91), pois há disposição expressa da sua cumulação com aquela imposta pelo item 14.3. No tocante aos produtos adquiridos pelos requeridos, incide a cláusula 14.5 do contrato, supramencionada.

Dessa forma, em que pese a franqueadora ter manifestado expressamente a intenção de retorno das mercadorias à fornecedora, "Se a FRANQUEADORA não exercer seu direito de opção, a FRANQUEADA poderá comercializá-los junto a terceiros, exceto aqueles que tiverem a identificação visual que remeta à MARCA e que não puderem ser descaracterizados, que deverão ser inutilizados completamente."

Por conseguinte, as partes devem cumprir a avença, utilizando-se, se assim entender, a via adequada para exigir o adimplemento dos réus em relação à fornecedora homologada.

Destarte, é caso de condenar os réus à multa rescisória proporcionalmente reduzida e ao pagamento da multa pelo descumprimento da cláusula de não concorrência, no valor de R\$ 100.000,00.

Da Reconvenção

Em sede de reconvenção os réus reconvintes pedem a declaração de rescisão do contrato de franquia por culpa da autora; o reconhecimento da nulidade da cláusula 16.2, de não-concorrência; a condenação da franqueadora à devolução da taxa de franquia paga, bem como no pagamento de multa contratual prevista na cláusula 14.3, no valor de R\$ 16.500,00, pela rescisão antecipada.

Inicialmente, o fato de a autora não ser titular de marca registrada no INPI não macula o contrato de franquia, haja vista ser o nome empresarial Vinho & Ponto Franchising Ltda., utilizando o nome fantasia Vinho & Ponto.

Saliente-se que o nome empresarial serve para identificar o empresário, quer seja individual, ou sociedade empresária, já as marcas, são designativos para identificar os produtos e serviços, ambos possuem um valor econômico, por isso são protegidos contra as utilizações indevidas.

Ressalve-se que consta de forma expressa do contrato de franquia que a franqueadora possui autorização para uso e exploração da marca Vinho & Ponto, com pedido de registro da marca de serviço mista em seu nome (fls. 63), fazendo jus à proteção marcária, ainda que precária, com fundamento no art. 130 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Observo que o contrato pactuado pelas partes tem natureza empresarial, presumindo-se, portanto, que são qualificadas e habituadas com os negócios mercantis pactuados.

Como ensina Paula Forgioni, o funcionamento do mercado exige que os pactos sejam respeitados, de forma que "A força obrigatória dos contratos viabiliza a existência do mercado, coibindo o oportunismo indesejável das empresas" (in Contratos

Empresariais. Teoria e Aplicação, 3ª ed., pp. 109/112, São Paulo, RT, 2018).

Ainda sobre o *pacta sunt servanda*, a Professora aponta que “Se lhes fosse permitido, os agentes econômicos valer-se-iam dos contratos para vincular apenas seus parceiros comerciais, e nunca a si próprios. No momento inicial, as partes creem que o negócio ser-lhes-á vantajoso; todavia, com o passar do tempo, é possível que o vínculo deixe de interessar a uma delas. Nasce anseio de se livrar da amarra contratual para seguir outro caminho. Partindo dessa premissa, compreende-se a importância sistêmica da força vinculante dos contratos; na sua ausência, seria impossível a coibição do descumprimento da palavra empenhada e o desestímulo de comportamento oportunistas prejudiciais ao tráfico. O princípio “*pacta sunt servanda*” mostra-se necessário ao giro mercantil na medida em que freia o natural oportunismo dos agentes econômicos” (op. cit – grifado).

Após detida análise dos autos, os réus/reconvintes não demonstraram os fatos que motivariam a responsabilização da autora/reconvinda pelo fracasso da empreitada. Com efeito, não foi possível verificar qualquer imposição da requerida sobre a escolha do ponto comercial. Os documentos juntados aos autos demonstram que houve trocas de informações entre as partes, sendo que foram apresentados todos os dados necessários sobre o negócio.

Desta forma, o contrato é inevitavelmente válido, salientando que não foi apontado eventual motivo concreto para justificar conclusão contrária.

No mais, em relação à alegação das mudanças tributárias, incabível responsabilizar a requerente reconvinda. Além disso, não houve qualquer início de prova de que tal circunstância impossibilitou a execução do contrato.

Ademais, o conjunto probatório dos autos permite concluir o suporte prestado pela autora-reconvinda, conforme os e-mails e documentos juntados (fls. 116, 257/265, 267/269, 275/276).

Registre-se que a escolha do ponto comercial é responsabilidade da franqueada (fls. 71).

Assim, a notificação extrajudicial foi enviada quase três anos após a celebração do contrato (fls. 104/110) e a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual prejuízo.

Ora, não há prova nos autos no sentido de que a autora tenha deixado de atender às solicitações da ré, sendo que os documentos acima aludidos indicam no sentido diverso.

Não é razoável imaginar que a franqueada, sem reclamar formalmente, tenha convivido com sensível falta de suporte e a existência de graves problemas com material, Considerando-se, ainda, que tal situação perdurou por mais de três anos.

Neste ponto, é importante observar que a prova meramente oral é insuficiente para a demonstração da falha na prestação de assessoria pela autora, eis que no caso está desprovida de qualquer amparo em documentos.

Ora, como já mencionado, não é crível que falhas sensíveis na transferência de know how e no assessoramento não tenham registro.

Portanto, não foi demonstrada a existência de justa causa para a rescisão do contrato de franquia por culpa exclusiva da requerente, razão pela qual, a notificação extrajudicial de fls. 159/167 produziu os efeitos pretendidos pela requerente/reconvinda.

Por outro lado, o contrato contém obrigação de não concorrência pelo prazo de dois anos após o término do contrato (cláusula 16.2 – fl. 91).

E não se vislumbra ilegalidade na obrigação de não concorrência, tal como contratada pelas partes.

Em que pese a livre iniciativa conste expressamente dos arts. 1º, IV, e 170, caput e IV, da CF, as partes são maiores e capazes e os negócios jurídicos versaram sobre direitos patrimoniais disponíveis, o que garante ampla liberdade para que as cláusulas sejam estabelecidas de acordo com a melhor conveniência das partes.

Mais ainda, como já mencionado, tratando-se de contrato empresarial, há presunção de que as partes são habituadas aos negócios que participam, tendo tomado as cautelas necessárias para a exata compreensão das obrigações assumidas, assim como das consequências.

Por tais razões, é inevitável reconhecer a incidência mais acentuada da autonomia

privada e do pacta sunt servanda.

Além disso, conforme já decidido, a cláusula observou os requisitos necessários, quais sejam, limitação territorial e temporal.

No caso, não se vislumbra qualquer nulidade na pactuação da obrigação de não concorrência, sendo que a melhor aplicação da boa-fé objetiva é exatamente no sentido da manutenção das obrigações validamente assumidas.

Suas consequências, por mais que eventualmente significativas, estão abrangidas no âmbito das justas expectativas.

Nesse sentido, os documentos de fls. 118/119 e as imagens de fls. 18/22 demonstram que a ré e seus sócios, ora reconvintes, passaram a desenvolver atividade concorrente, o que, aliás, não foi impugnado.

E como já apontado, a notificação extrajudicial enviada pela autora/reconvinda produziu os efeitos pretendidos, eis que há justa causa para a rescisão do contrato.

Portanto, restou demonstrada a efetiva concorrência realizada pelos réus reconvintes, em evidente contraposição ao que foi contratualmente estabelecido pelas partes.

Assim, repita-se, há que se reconhecer que a parte ré deu causa à rescisão dos contratos de franquia, por não terem encerrado as atividades com a observância das regras estabelecidas pelas partes, desenvolvendo atividade concorrente, o que era expressamente proibido (cláusula 16.2 - fl. 91).

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da cláusula de não-concorrência, ou devolução da taxa de franquia, tampouco de pagamento pela autora/reconvinda da multa rescisória.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PRINCIPAIS, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso I, CPC, tornando definitiva a tutela de urgência deferida, para:

a) declarar a rescisão do contrato de franquia pactuado entre as partes, por culpa dos réus;

b) condenar os réus ao cumprimento das obrigações pós-contratuais de não-concorrência, "encerrando as atividades empresariais no local [onde estava estabelecida a unidade franqueada no município de Dourados/MS], abstendo-se de continuar com os serviços de venda de bebidas, sobretudo vinhos, na Rua Monte Alegre, 2655, Dourados/MS, durante o prazo de 2 (dois) anos" contado a partir da notificação da rescisão extrajudicial do contrato de franquia, que se deu em 24/09/2020, nos termos da cláusula 16.2 do contrato de franquia.

c) condenar os réus ao cumprimento das demais obrigações pós-contratuais, com a cessação do uso da marca da autora, a devolução de materiais e manuais e confidencialidade (cláusulas 14.4, 14.7 e 16.1);

d) condenar os réus ao pagamento de multa rescisória do item 14.3 do contrato proporcionalmente reduzida, pelo tempo restante para o término do contrato com prazo de vigência de 5 anos, tendo em vista que o termo do referido prazo se daria em 23/10/2022 e que a rescisão se operou em 24/09/2020, acrescida de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do E. TJSP, contados da rescisão e de juros de mora de 1% a.m., a partir da data da citação;

e) condenar os réus ao pagamento da multa de R\$ 100.000,00 (cláusula 16.2 - fls. 91), atualizada pela média dos índices IGP-M, IPC e INPC, desde a data da rescisão (cláusula 16.2 - fls. 91) e de juros de mora de 1% a.m. desde a citação;

f) determinar que a apuração dos valores devidos depende de mero cálculo aritmético (art. 509, § 2º, do CPC), que deverá ser elaborado diretamente pelo credor;

g) com fundamento no - art. 85, § 2º, do CPC, condenar a parte ré ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado pelo autor, fixados em 20% do valor da condenação. Observo que em relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da condenação. Em relação aos honorários advocatícios, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura da ação, bem como de juros de

mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Sem prejuízo, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos reconventionais, com a extinção do processo, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.

Sucumbentes, condeno os réus/reconvintes no pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado pelo autor, fixados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Observe que em relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da condenação. Em relação aos honorários advocatícios, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

P.I.C.

São Paulo, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA